

1500113-35.2022.8.26.0283

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... jurisprudencial:

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - AFASTADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (40 KG DE MACONHA) TRÁFICO INTERESTADUAL - APLICADO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - REGIME PRISIONAL FECHADO - RECURSO PROVIDO. Não preenchidos os requisitos legais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500113-35.2022.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500113-35.2022.8.26.0283

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MICHELOTTO ROCHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

RAFAEL MICHELOTTO ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de junho de 2022, por volta das 22h30min, na Rodovia SP 310, Km 216, zona rural, neste Município e Comarca de Itirapina, RAFAEL MICHELOTTO ROCHA, qualificado às fls. 10, transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 221 (duzentos e vinte e um) tijolos de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 150 (cento e cinquenta) quilos no total, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06 e exame toxicológico definitivo de fls. 73/74), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado à fls. 170 e apresentou defesa preliminar (fls. 152/158).

A denúncia foi recebida em 07/08/2022 (fls. 171/180) e o acusado foi citado.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a acusada. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia; Por outro lado, a Defesa: i) pugnou pela improcedência da ação penal; ii) requereu, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena.

É o relatório. DECIDO.

II - Fundamentação

A materialidade foi demonstrada pelo auto de constatação preliminar (fl. 07), auto de exibição e apreensão (fls. 06) e laudo pericial (fls. 73/74).

A autoria também é certa e deve ser atribuída ao acusado.

A testemunha Marcos Vinicius Gritti De Castro declarou que, no dia dos fatos, por volta das 22h30, durante fiscalização pela praça de pedágio situada no km 216 da rodovia SP 310, notou que o motorista do veículo VW/Gol, placa DCA8424, apresentou extremo nervosismo ao avistar a viatura, razão pela qual resolveu abordá-lo. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com ele, porém, em busca veicular, no banco de trás do veículo, bem como no porta malas, foram localizados 221 tablets de maconha, com cerca de 150 Kg, além de aparelho celular. Afirma que Rafael relatou ter feito contato com indivíduo não identificado na cidade de Jundiaí, que lhe ofereceu a quantia de R\$ 4.000,00 para transportar a droga para uma cidade que lhe seria informada durante o trajeto. Diante dos fatos, dada voz de prisão em flagrante e conduzido o réu à unidade competente.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Miguel Vasques Petruz.

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Nessa linha também: "[...] 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes." (REsp 1302515 /RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

O depoimento das testemunhas foi corroborado pela confissão do acusado. Rafael, ao ser interrogado, confessou os fatos a ele imputados. Disse que passava por dificuldades financeiras, pois sofreu um acidente recentemente e seu pai estava em tratamento para câncer. Como estava difícil arrumar trabalho, um de seus amigos, que possuía envolvimento com o mundo do crime, falou que poderia lhe indicar para realizar um "serviço" em que receberia um valor considerável. Assim, depois de topor a empreitada, ficou combinado que ganharia quatro mil reais caso levasse a droga em seu carro para o local que lhe seria informado durante o trajeto.

Portanto, o intuito da traficância foi provado em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 150 kg), pelas circunstâncias da apreensão (em rodovia) e pela própria finalidade confessada pelo acusado.

A jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação

criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347)

Registro ser inviável a aplicação do benefício do arrependimento eficaz, uma vez que o crime já havia se consumado com a conduta de "transportar" droga.

Comprovadas a autoria e materialidade, não havendo qualquer causa excludente, de rigor a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)." (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

Na PRIMEIRA FASE, verifico que a quantidade de entorpecente apreendido é considerável. Acerca da natureza da droga, tem-se que o exercício diuturno da jurisdição nos ensina que "crack", cocaína e maconha são substâncias indiscutivelmente nocivas, mas facilmente encontradas em qualquer cidade. Portanto, sua natureza, neste cenário real instalado, não evidencia fator de *discrimen habili* a justificar elevação da sanção, sob pena de se transformar em regra praticamente absoluta a elevação de pena na 1ª fase da dosimetria nos processos por tráfico de drogas. De consequente, a aplicação prudente da Lei Penal sinaliza que apenas substâncias de natureza excepcional, tais como ópio, LSD, heroína, ecstasy, etc, poderiam justificar maior rigor na primeira fase da dosimetria. Dessa forma, de acordo com o art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, presente a atenuante da confissão espontânea, torno a pena ao seu patamar mínimo.

Na TERCEIRA FASE, não há como se aplicar a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, de acordo com os C. STJ e STF, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

(...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

E, enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, apurados a partir da Folha de Antecedentes do réu, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base (i) na quantidade e/ou variedade e/ou nocividade da(s) droga(s) apreendida(s); (ii) na própria Folha de Antecedentes; (iii) no modo/forma de acondicionamento da(s) droga(s); (iv) no próprio *modus operandi* do tráfico de drogas; (v) na conduta social do(s) réu(s); (vi) nos instrumentos destinados ao tráfico de drogas (balança, anotações de contabilidade, armas, pinos, sacos para dosagem etc.)

eventualmente apreendidos; (vii) no concurso eventual de agentes; (viii) na apreensão de expressiva quantidade de dinheiro associada à ausência de comprovação de atividade lícita ou apreensão de dinheiro em notas miúdas; (ix) no local da abordagem; (x) ausência de ocupação lícita. Conferir:

(...) 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (RHC nº 116.926/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13). 5. Não se constata ilegalidade flagrante na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão aplicada ao paciente, pois essa tem por base, como se verifica no acórdão da apelação, as condições subjetivas valoradas negativamente. 6. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao paciente torna prejudicada, por si só, a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 7. Habeas corpus denegado. (STF, HC 127241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 destaque adicionado)

(...) 2. Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às atividades criminosas. 3. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 4. O habeas corpus não é prestante para revisar os elementos de prova invocados pelas instâncias de mérito a refutar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento. (STF, RHC 94806, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010, DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-02 PP-00785 destaque adicionado)

Ademais, a “(...) primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao deferimento do benefício, pois, nos termos do que contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena depende, ainda, de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, (...)” (STF, HC 98366, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-01 PP-00192).

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já considerou como quantidades indicadoras de dedicação à atividade criminosa os seguintes parâmetros: a) “(...)

4. A quantidade e natureza das drogas apreendidas (in casu, 18,5 g de maconha e 14,8 g de cocaína, sendo parte na forma de crack), por indicar dedicação a atividades criminosas, pode embasar o não reconhecimento do tráfico privilegiado. (...)” (STJ, HC 326.519/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 03/08/2016 destaque adicionado); b) “(...) 2. Os

fundamentos utilizados pela Corte Estadual para não aplicar ao caso concreto a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (7,4g de maconha, acondicionadas em 3 invólucros plásticos; 39,8g de “crack”, acondicionadas em 117 invólucros plásticos; e 32g de cocaína, acondicionadas em 64 papелotes), está em consonância com o entendimento desta Corte. (...)” (STJ, HC 322.661/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016 destaque adicionado); c) “(...) 2. Os fundamentos utilizados pela Corte Estadual para não aplicar ao caso concreto a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (22 cápsulas de cocaína, pesando 18,87g, 21 invólucros de “crack”, pesando 12,9g, e 21 invólucros de ‘maconha’, pesando 21,71g), está em consonância com o entendimento desta Corte. (...)” (STJ, HC 296.548/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016); d) “(...) Hipótese em que o

Tribunal de origem conferiu legalidade à manutenção do não reconhecimento do privilégio, ao fundamentar que a quantidade, a variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (15,13 gramas de cocaína e 26,23 gramas de crack), aliadas às circunstâncias em que o delito ocorreu, permitem concluir que o acusado dedica-se a atividades criminosas. (...)." (STJ, HC 362.266/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016 destaque adicionado); (e) "(...) - À luz da jurisprudência desta Corte, é de ser mantido o afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão fundamenta-se na quantidade e na variedade das drogas apreendidas, quais sejam, 42 porções de cocaína, com peso de 26,87g; 05 porções de maconha, com peso de 9,54g; e 14 porções de crack, com peso de 6,43g, circunstâncias aptas a indicar que o paciente dedicava-se a atividades ilícitas, a embasarem o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. (...)." (STJ, HC 301.828/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015 destaque adicionado).

Por sua vez, aquele mesmo Colendo Tribunal já apontou como quantidades que autorizam a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06: (i) "(...) - No caso, sendo o paciente primário e tendo em vista a pequena quantidade da droga apreendida, qual seja, 5 gramas de crack, não há elementos concretos a indicar, juntamente com as circunstâncias do delito, que integre organização criminosa ou dedique-se às atividades ilícitas. (...)." (STJ, HC 364.447/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/09/2016 destaque adicionado); (ii) "(...) - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. (...)." (STJ, HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016 destaque adicionado); (iii) "(...) - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que os pacientes dedicam-se às atividades criminosas pelo fato de não exercerem atividade lícita, pois estavam desempregados à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida (13 cápsulas de cocaína, pesando 9,9 gramas), apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação dos acusados às atividades ilícitas. (...)." (STJ, HC 313.899/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016 destaque adicionado); (iv) "(...) 6. Nem mesmo a quantidade de drogas apreendidas - admitida por esta Corte como fundamento idôneo para justificar a recusa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - autorizaria tal negativa no caso concreto, que cuida de tráfico de 0,9 g de crack." (STJ, REsp 1434029/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015 destaque adicionado).

Nesse contexto, inaplicável a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando a grande quantidade de droga apreendida, o fato de o próprio réu ter declarado que possui diversos amigos envolvidos com o crime organizado, entendo que há provas de que o réu possuía uma relação mais estreita com o mundo do crime, o que afasta a aplicação do benefício pretendido.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - AFASTADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (40 KG DE MACONHA) TRÁFICO INTERESTADUAL - APLICADO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - REGIME PRISIONAL FECHADO - RECURSO PROVIDO. Não preenchidos os requisitos legais previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não há se falar em aplicação da aludida benesse. Restando demonstrado pelas provas dos autos que o agente tinha a intenção de transportar a droga para outro estado da federação, resta caracterizada a majorante contida no inciso V, do art. 40, da Lei n. 11.343/06. No caso, impõe-se o regime fechado, mais gravoso que a pena de 5 anos

comporta, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (40 kg de maconha). (TJ-MS - APR: 00010121320178120012 MS 0001012-13.2017.8.12.0012, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 05/12/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2018)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA - CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONFISSÃO - REDUÇÃO PROPORCIONAL - FRAÇÃO DA MAJORANTE DE TRÁFICO INTERESTADUAL CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECURSO DESPROVIDO. A premeditação do agente é elemento hábil para negativar a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista do no art. 59 do CP. Precedentes. Afigura-se proporcional a redução de quatro meses na pena intermediária em virtude da confissão espontânea do agente. A fração de ½ (metade) aplicada à majorante de tráfico interestadual se justifica pela grande distância percorrida e o número de fronteiras estaduais que seriam ultrapassadas até o destino final da droga, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem. Precedentes do STJ. (Ap 149751/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017) (TJ-MT - APL: 00067805320158110064 149751/2016, Relator: DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, Data de Julgamento: 19/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2017)

Tem-se a pena final de: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Valor da Pena de Multa

0 dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Regime de Cumprimento de Pena - Substituição de Pena - "Sursis"

Por conseguinte, em observância aos arts. 33 e 59, do Código Penal, ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, e notadamente às peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (quantidade de droga apreendida, forma de armazenamento, e o quantum da pena aplicada), fixo o regime inicial SEMIABERTO.

Por seu turno, ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal). De fato, a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

III - Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RAFAEL MICHELOTTO ROCHA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em regime inicial SEMIABERTO.

Aplicação do artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal

Apesar do disposto no § 2º do art. 387 do Código Processo Penal, o período da prisão provisória não altera o regime inicial aplicado, conforme intervalos delimitados pelo art. 33, § 2º, do Código Penal. Ademais, já foi consignado por diversas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça a impossibilidade, em regra, do juízo de conhecimento examinar todos os requisitos (objetivos e subjetivos) para aplicação do § 2º do art. 387 do CPP.

Por derradeiro, não há como se efetuar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal com as alterações trazidas pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, eis que não há nos autos informes sobre eventual comportamento carcerário dos réus, ou existência de demais processos, sendo que a solicitação de apresentação de informações ao Juízo competente postergaria o

desfecho dos autos. (TJSP, Apelação nº 0086558-34.2014.8.26.0050, Relator(a): Silmar Fernandes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 13/04/2016; Data de registro: 17/04/2016)

“Note-se que, a despeito da redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.736/12, não fazem jus os apelantes à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime aberto ou semiaberto, em razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. Para tal fim, impor-se-ia a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, que é verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.” (TJSP, Apelação nº 3001370-97.2013.8.26.0586, Relator(a): Toloza Neto; Comarca: São Roque; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016)

No mesmo sentido: TJSP, Apelação nº 0014589-90.2013.8.26.0050, Relator(a): Fernando Simão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/04/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 0005798-98.2011.8.26.0666, Relator(a): Louri Barbiero; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0036726-32.2014.8.26.0050, Relator(a): Ivana David; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 3001984-22.2013.8.26.0451, Relator(a): Marcelo Gordo; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0002152-62.2015.8.26.0562, Relator(a): Walter da Silva; Comarca: Santos; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0037963-04.2014.8.26.0050, Relator(a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0006176-32.2014.8.26.0510, Relator(a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016; TJSP, Apelação nº 0050595-28.2015.8.26.0050, Relator(a): Marco de Lorenzi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 11/04/2016; TJSP, Apelação nº 0014054-93.2015.8.26.0050, Relator(a): José Damião Pinheiro Machado Cogan; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 08/04/2016; TJSP, Apelação nº 0099213-38.2014.8.26.0050, Relator(a): Edison Brandão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Apelação nº 0034156-81.2013.8.26.0576, Relator(a): Nuevo Campos; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2226128-20.2015.8.26.0000, Relator(a): Ricardo Tucunduva; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/12/2015; Data de registro: 07/12/2015.

Direito de Recorrer em Liberdade

Em respeito ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, nego ao(s) réu(s) o direito de recorrer(em) em liberdade, uma vez que: (i) persistem os motivos que deram causa à(s) sua(s) prisão(ões) preventiva(s)², não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) o regime inicial semiaberto imposto não se coaduna à permanência em liberdade na fase recursal; (iii) não há sentido em que o(s) sentenciado(s), que respondeu(ram) preso(s) durante todo o processo, seja(m) solto(s) quando da sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais, a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Nesse sentido: TJSP, Habeas Corpus nº 2202942-31.2016.8.26.0000, Relator(a): Nelson

Fonseca Junior; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2016; Data de registro: 07/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2183672-21.2016.8.26.0000, Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: Bertioga; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Apelação nº 0004271-73.2015.8.26.0019, Relator(a): Ely Amioka; Comarca: Americana; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2183417-63.2016.8.26.0000, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Avaré; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 30/09/2016.

No entanto, considerando o regime inicial semiaberto imposto ao réu, deverá ser imediatamente colocado em estabelecimento prisional compatível. Nessa linha: TJSP, Habeas Corpus nº 2012289-72.2016.8.26.0000, Relator(a): Grassi Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 22/09/2016; Data de registro: 27/09/2016, STJ, RHC 39.060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014; STJ, HC 273.492/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013; STJ, RHC 30.735/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

Expeça-se mandado de recomendação. Oficie-se com urgência.

Despesas Processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I)

Condene o(s) ré(u)(s) ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza em execução.

Honorários Advocatícios

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Objetos, coisas e valores eventualmente apreendidos

Em relação a objeto(s), coisa(s), valor(es) e importância(s), eventualmente, apreendido(a)(s) que não tenha(m) sido reclamado(s) por terceiro(s) interessado(s), DETERMINO: (i) tratando-se de bens móveis servíveis e veículos, sua perda e a observância do art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (ii) tratando-se de bens imprestáveis, sua perda e observância do art. 516, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iii) se se tratar(em) de veículos, cujo estado de conservação ou a adulteração de chassi inviabilizem a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias, a contar da data da apreensão, sua perda e a observância do art. art. 516, §§ 3º e 4º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iv) tratando-se de valor(es) e/ou importâncias, após oitiva do Ministério Público e não havendo impugnação, determino sua perda em favor do Fundo Penitenciário, com fulcro no art. 518, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Tratando-se de condenação por crimes previstos na Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e havendo bens móveis, imóveis ou valores (consistentes em produtos dos crimes previstos no referido Diploma ou ainda que constituam proveito auferido com sua prática) apreendidos que não tenham sido restituídos ou reclamados nos termos do procedimento previsto no art. 60, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.343/06, determino seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Fiança Eventualmente Recolhida

Quanto à eventual valor recolhido a título de fiança, destaco, desde logo, que nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal “(...) o saldo [da fiança] será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.” (destaque adicionado). Na mesma linha, “(...) a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas e também da multa (se for aplicada). (...)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2015).

Além disso, a fiança pode inclusive ser utilizada para quitação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (STJ, RHC 68.142/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Portanto, após as deduções, se não reivindicado o valor restante de fiança recolhida, no prazo de 10 (dez) dias em seguida ao trânsito em julgado definitivo, determino sua perda em favor do Tesouro Nacional, com base no art. 483 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I.

Disposições Finais

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(s) réu(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal ; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; IV) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença; V) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal.

Se arma(s) de fogo e/ou munição(ões) tiver(em) sido apreendida(s), já havendo o(s) respectivo(s) laudo(s) pericial(is) anexado(s) aos autos, bem como cumprimento do art. 509, caput, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I, determino (i) o encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, para destruição, com a comunicação à Secretaria de Estado da Segurança Pública (art. 511 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I); (ii) e, se se tratarem de arma(s) de fogo e/ou munição(ões) que pertença(m) à Polícia Civil ou Militar ou às Forças Armadas, cumpra a z. Serventia o § 4º do art. 509 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itirapina, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA